

中国与 DEPA 数据跨境流动： 规制差异及制度对接探究^{*}

齐 鹏^{**}

内容摘要：中国加入 DEPA 是构建新发展格局、深化全球数字贸易伙伴关系的重要战略举措，不仅彰显了我国开放创新包容的发展理念，也是推动引领全球数字经济治理的重要举措。为有效弥合与 DEPA“新式”数据治理规则之间的张力分歧，有必要围绕 DEPA 模块 4 中“个人信息保护、数据跨境流动及数据本地化存储”三个核心议题展开深入研究。通过系统梳理全球数据跨境多极治理格局及 DEPA 运行现状，比对中国与 DEPA 数据跨境流动规则的差异，进而探索具有中国特色的数据跨境流动“中式”方案：一是在个人信息安全保护规则方面，扩大个人信息保护边界，构建个人信息保护法律体系，强化数据跨境传输中个人信息保护机制兼容互认；二是在数据跨境流动规则方面，秉持“构建数字空间命运共同体”价值理念，强化国际合作筑牢数据跨境流动安全防线，准确把握数据流动和安全发展的平衡点；三是在数据本地化存储规则方面，形成与 DEPA 各国立法互相尊重的透明规则，推进与 DEPA“本地化为原则+合法公共政策为例外”的数据跨境本地化模式的制度衔接。

关键词：数据跨境流动 DEPA 个人信息保护 数据存储本地化

DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2025.03.003

引言

数据要素作为数字经济关键生产资料，其跨境流动能够充分发挥数据生产要素的乘数效应，推动全球产业链和供应链的重新分配。^①随着数据流动规模不断扩大，相关经济基础已发生显著变化，亟需构建与之适配的上层建筑法律规则体系，以保障数据质量、降低数据收集成本，并促进数字贸易可持续发展。对此，各国围绕数据跨境流动治理规则如何构建展开了激烈角力，^②这种规则博弈已成为全球战略竞争的新兴战场。在该战场下，发达国家凭借技术优势和经济实力，更加容易掌握全球数据并从中获取大量收益；而欠发达国家则面临收益有限甚至被“数据殖民”的风险。^③在全球数字贸易规则主张存在显著分歧的情况下，由“第三极”小型经济体发起、具有弹性特质的全球首个数字贸易专项协定——《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)，以其开放包容的合作理念，为弥合中美欧数字规则分歧提供了“新路径”，也为中国数字经济规制创新开启了“新窗口”。^④

然而遗憾的是，数据跨境流动相关文献虽早已汗牛充栋，但既有研究或聚焦中国数据跨境流动宏观规制

* 本文系国家社科基金一般项目“中国高科技企业跨境数据流动风险防范研究”(项目编号:24BGJ031)的阶段性成果。

** 西安交通大学法学院副教授。

① 参见叶开儒：《数据跨境流动规制中的“长臂管辖”——对欧盟 GDPR 的原旨主义考察》，载《法学评论》2020 年第 1 期。

② 参见李宏兵、柴范、翟瑞瑞：《跨境数据流动的 global 态势、规则比较与中国策略》，载《国际经济合作》2023 年第 6 期。

③ 参见石静霞、陆一戈：《DEPA 框架下的数字贸易核心规则与我国的加入谈判》，载《数字法治》2023 年第 1 期。

④ 参见周念利、于美月：《中国应如何对接 DEPA——基于 DEPA 与 RCEP 对比的视角》，载《理论学刊》2022 年第 2 期。

模式,^⑤或关注欧美处理数据跨境流动方式异同对比,^⑥或侧重 DEPA 内容特点分析,^⑦对中国与 DEPA 数据跨境流动规则如何具体有效对接的分析付之阙如。为推进中国加入 DEPA 谈判进程,加快对接 DEPA 高标准规则,推进建章立制步伐,^⑧本文试图以全球数据跨境多极治理格局及“新式”范式为切入点,聚焦 DEPA 模块 4 中“个人信息保护、数据跨境流动及数据本地化存储”三个核心议题,审慎剖析比较 DEPA 与既有规制策略及中国数据跨境流动规则差异,并就如何实现与 DEPA 数据跨境流动规则有效对接提出一隅之见,以供理论界与实务界参考。

一、全球数据跨境多极治理格局及“新式”范式

随着互联网技术的不断成熟和数据流动的持续扩张,地缘政治已延伸至网络空间,形成了新型的网络地缘政治格局。在网络地缘政治的影响下,全球数据跨境流动的冲突日益加剧,严重制约了数据要素价值的充分释放。^⑨为突破网络地缘政治对数据跨境流动的限制,降低数字贸易中的制度性壁垒,全球范围内已逐步形成了由多边、双边和区域数据跨境经贸规则共同构成的多极竞争格局。

(一)全球数据跨境流动多边经贸规则

数据作为新型生产要素,在具体应用中通过将传统实体贸易与电子商务产业价值链深度融合,形成了货物贸易与技术服务紧密捆绑的数字贸易新结构。^⑩在多边经贸规则层面,世界贸易组织(WTO)作为全球贸易争端的准司法机构,虽早于全球数据流动的爆炸性增长便意识到数字贸易中数据流动对贸易形态带来的深刻变革,^⑪但在协议谈判初期并未将数字产品和服务纳入规制范围。直至 1998 年 9 月总理事会通过《电子商务工作计划》,才首次提出“电子商务”概念,开启了 WTO 对电子商务议题的探索。^⑫后续电子商务相关问题被逐步纳入《服务贸易总协定》(GATS)框架,但其规制范围仅限于特定领域,对数据跨境流动规则仍然空缺,以致《GATS 第四议定书》签署后,许多成员国未就数据跨境流动作出明确承诺,^⑬难以充分应对数字贸易新特征及例外条款滥用等问题。为弥合 GATS 规定之不足,2017 年 71 个 WTO 成员发起了电子商务联合声明倡议(JSD),^⑭并于 2019 年由 76 个成员共同签署《关于电子商务的联合声明》,正式启动电子商务贸易相关规则的谈判。其中,以美国为代表的发达经济体主张数据跨境自由流动,反对数据本地化要求;以

⑤ 参见金晶:《作为个人信息跨境传输监管工具的标准合同条款》,载《法学研究》2022 年第 5 期;张凌寒:《个人信息跨境流动制度的三重维度》,载《中国法律评论》2021 年第 5 期;何波:《中国参与数据跨境流动国际规则的挑战与因应》,载《行政法学研究》2022 年第 4 期;徐拥军、王兴广:《总体国家安全观下的跨境数据流动安全治理研究》,载《图书情报知识》2023 年第 6 期;丁晓东:《数据跨境流动的法理反思与制度重构——兼评〈数据出境安全评估办法〉》,载《行政法学研究》2023 年第 1 期。

⑥ 参见李艳华:《隐私盾案后欧美数据的跨境流动监管及中国对策——软数据本地化机制的走向与标准合同条款路径的革新》,载《欧洲研究》2021 年第 6 期;洪延青:《数据竞争的美欧战略立场及中国因应——基于国内立法与经贸协定谈判双重视角》,载《国际法研究》2021 年第 6 期;夏菡:《国际法视野下欧盟数据治理立法发展及对中国的启示》,载《武大国际法评论》2023 年第 4 期;金晶:《欧盟的规则,全球的标准?——数据跨境流动监管的“逐顶竞争”》,载《中外法学》2023 年第 1 期。

⑦ 参见季烨、霍俊先:《契合 RCEP 理念的数据保护法域外效力规则的建构》,载《国际贸易》2023 年第 12 期;陈喆:《DEPA 数据开放共享规则:中国立场与规则对接》,载《学术论坛》2023 年第 6 期;李猛:《我国对接 DEPA 国际高标准数字经济规则之进路研究——以参与和引领全球数字经济治理为视角》,载《国际关系研究》2023 年第 3 期。

⑧ 参见靳思远、沈伟:《〈数字经济伙伴关系协定〉的科技战略导向和中国选择进路》,载《中国科技论坛》2023 年第 2 期。

⑨ See Tianran Liu, Administrative Law Regulation of Cross-border Data Flows: A Case Study of Critical Technology Sectors, Economics, Law and Policy, Vol. 7, No. 3, 2024, pp. 118—147.

⑩ See Mira Burri & Kholofelo Kugler, Regulatory Autonomy in Digital Trade Agreements, Journal of International Economic Law, Vol. 27, 2024, pp. 397—423.

⑪ 1995 年 1 月生效的《服务贸易总协定》规定,除保护敏感数据、个人隐私等特殊场景外,WTO 成员国间应允许通过网络自由跨境数据传输。

⑫ See WTO, E-Commerce, https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm, accessed 10 October 2024,最后访问日期:2024 年 10 月 10 日。

⑬ 参见张丽、孙菲阳:《跨境数据流动全球治理趋势与我国规制策略》,电子工业出版社 2022 年版,第 31 页。

⑭ See WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/1056.pdf&.Open=True>, accessed 15 October 2024,最后访问日期:2024 年 10 月 15 日。

中国为代表的发展中国家则主张建立以货物流动为主的跨境电子商务规则;而非洲、加勒比和太平洋岛国等成员国则反对将跨境电子商务议题纳入多边贸易框架。囿于各方立场显著分歧,尽管 2023 年 12 月 WTO 最后一轮谈判结束后,JSI 成员已基本完成 13 个条款谈判,但截至目前仍未就数据跨境流动、数据本地化等核心问题达成实质性谈判成果。

当前 WTO 在数据跨境流动规则制定方面仍未取得突破性进展,尚未建立起专门的数据跨境流动协议,究其缘由:第一,WTO 在制定适应全球新形势的数字贸易规则方面相对滞后,突出表现为未能明确界定数据流动的性质。当数据作为服务进行贸易时,其货物与服务属性之间的界限难以准确界定。尽管 GATS 依据《服务部门分类表》^⑮对全球服务领域进行了划分,但该分类并未将新兴的数据服务纳入其中,这意味着数据流动尚未被认定为 GATS 的服务类型。第二,由于缺乏统一的国际规则,WTO 专家组在评估数据限制措施是否符合 GATS 一般例外或安全例外情形时,往往需要结合成员国的具体承诺考量。然而,由于各国和地区的价值取向与利益诉求存在根本差异,尤其是数据自由流动和数据本地化存储可能涉及公民权利或个人隐私等问题,导致各成员国在数据跨境流动规制方面的协调或相互承认的可能性较低。第三,WTO 采用的诸边谈判模式在多个议题谈判进程停滞不前,形成大量分散协定,导致数字贸易规则过于碎片化,^⑯无法为成员国提供清晰明确的规范参考,不仅给相关企业的数据管理带来了巨大挑战,也最终弱化了数据治理的整体效果。

(二)全球数据跨境流动多极竞争模式

在 WTO 多边数据跨境流动规则制定受阻、难以适应数字贸易发展需求的背景下,美欧作为全球数字贸易的主要参与者,正试图将符合各自数字贸易发展诉求的区域性立法上升为国际标准,构建起以自身利益为核心的阵营化范式。

1. 倾向“美国优先”的美式进取范式

从世界数字贸易发展史看,美国作为全球互联网的发源地,孕育了众多具有广泛影响力和市场份额的大型互联网公司,并积累了海量数据资源。^⑰早在 1977 年经济合作与发展组织(OECD)隐私大会上,美国大法官路易·儒瓦内(Louis Joinet)就明确提出“数据具有经济价值,一国对于某些类别数据存储和处置能力能够赋予一国相对于他国政治和技术上的优势。反之,数据跨境转移会导致一国国家主权丧失”。^⑱基于这种主张,美国始终秉持以数据跨境流动为核心的价值取向,旨在推动美国互联网企业等私营主体的快速发展。为巩固其利益扩张目标,^⑲美国试图在欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)、亚太经合组织(APEC)框架以及《跨境隐私规则体系》(CBPR)间构建相互兼容的数字贸易规则体系,将美式主张嵌入全球规则框架中,进而强化其对全球数字贸易关键领域的垄断地位。

虽然美国尚未制定专门规制数据跨境流动的法律,但其已通过多种方式构建了以“美国优先”为核心的数据跨境流动范式。第一种范式:通过促使成员国降低自身数据保护标准,以迎合美国相对较低的数据保护要求,从而为企业获取数据跨境传输资格提供便利。为此,美国与欧盟先后确立了“安全港”和“隐私盾”等规则,试图通过变通方式达到欧盟所要求的“充分保护”水平。同时,美国凭借其在亚太地区的政治经济影响力,推动形成了《跨境隐私规则体系》(CBPR),要求各成员国尽量减少数据流动障碍,允许企业通过自我评估或第三方机构认证获得数据跨境传输资格,从而实现获证企业间数据自由流动。

^⑮ See B. S. Markesinis & Hannes Unberath, *The German Law of Torts: A Comparative Treatise*, Hart Publishing, 2002, p. 80.

^⑯ 参见史旻玥:《数字经济时代全球数字贸易规则的差异化发展及中国应对》,载《中国石油大学学报(社会科学版)》2023 年第 6 期。

^⑰ 印度国家科技与发展研究中心 1982 年发布的《跨境数据流动争议》报告表明,美国十家计算机企业占据全球 85% 计算机供应及数据服务,其中处理的数据 80% 存储在美国。

^⑱ See Joinet L, *Remarks Before the Organization for Economic Cooperation and Development Symposium on Transborder Data Flows and the Protection of Privacy*, <https://law.emory.edu/elj/elj-online/volume-64/responses/data-nationalism-its-discontents.html>, 1977, 最后访问日期:2024 年 9 月 12 日。

^⑲ 参见齐鹏:《数字经济背景下“一带一路”跨境数据传输的法律规制》,载《法学评论》2022 年第 6 期。

第二种范式:通过推广“数据跨境自由流动”模式,消除各国市场准入壁垒,以巩固美国在全球数据跨境领域的话语权。自 2010 年《韩美自由贸易协定》首次引入非强制性的数据跨境流动规定以来,美国逐步将这一理念转化为具有约束力的规则。其中,2016 年《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)将“数据跨境自由流动”作为硬性规定,而 2018 年《全面和进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)则在电子商务专章中进一步明确了相关规则。^①此外,2018 年《美墨加协定》(USMCA)第 19 章也明确要求各方不得限制数据跨境流动,^②并将 TPP 中电子商务内容升级为数字贸易专章,进一步强化美国在数据跨境流动领域规则主导权。

概观上述“美国优先”的美式进取范式,虽然其不鼓励国家对市场自由行为过多干预,但其倡导的数据跨境自由流动也并非完全自由化,^③而是存在一定双重标准。一方面,美国积极推动全球数据自由流动,以此作为维护其全球经济和技术领导地位的重要手段;另一方面,为保护其国内经济和技术利益,美国又采取了一系列限制性措施严格管控数字贸易上下游核心技术出口,^④这种双重标准反应了美国在数据跨境流动政策上的复杂性和矛盾性。总体而言,尽管美国范式倡导建立一个开放、自由的全球数字市场,但它对协议方在数字经济自由化、透明化和便利化方面的要求过高,一定程度上加剧了与发展中国家间的“数字鸿沟”,并超出了这些国家的安全承受能力。因此,以美式范式作为全球数字治理方案仍面临诸多挑战,^⑤其适用性和公平性仍需进一步完善。

2. 聚焦隐私保护的欧式规制范式

与美式规则不同,欧盟作为数据跨境流动治理先行者,在数据监管领域既倡导加快区域内数据跨境流动,又高度重视个人隐私数据保护,强调在严格保障隐私数据安全的前提下优化数字经济市场秩序。^⑥欧盟将个人数据保护视为基本人权,^⑦并通过事前防御机制保障个人隐私数据安全,防止境内数据生产要素流失。这种以“人权优先”和“充分保护”为核心的范式,主要源于欧洲在二战期间经历的法西斯和极权政权历史,战后欧洲社会对个人隐私保护极为重视,并将其视为基本人权的重要组成部分。相较美国,欧盟数字贸易发展以中小企业为主,其数字贸易实力较为偏弱,^⑧为保护并扭转各经济主体数据跨境流动中的劣势地位,欧盟不得不形成相对严苛标准。

欧盟关于数据跨境流动的规制,经历了从“公约”到“指令”,再到“条例”的演进过程,逐步从原则性规定走向具体化规则。其中,1981 年欧洲理事会通过的《第 108 号公约》(以下简称《公约》)是欧洲首个针对数据跨境流动的规制文件,旨在消除内部国界壁垒,推动成员国之间的数据跨境共享。《公约》第三章第 12 条第 2 款明确规定,不得仅以保护个人隐私数据为由限制缔约国间的数据流动。尽管《公约》初步形成了数据跨境流动的规制框架,但由于其允许成员国自行决定执行方式,导致各国实践差异较大,最终真正执行该公约的国家寥寥无几,欧盟对外也难以统一主张高水平的数据保护标准。

为弥补立法分散带来的困境,欧共体委员会于 1990 年开始起草欧盟层面的统一立法草案,并于 1995 年由欧洲议会和欧盟理事会通过《数据保护第 95/46/EC 号指令》(以下简称《指令》)。其中,《指令》第 5 条不

^① 第 14.11 条强调数据跨境流动应公平、有序进行,第 14.13 条则限制数据本地化措施的实施,要求其不得具有任意性、歧视性或构成贸易壁垒,且对数据流动的限制不得超过实现合法公共政策目标的必要限度。参见张倩雯、张文艺:《欧美跨境数据流动合作的演进历程、分歧溯源与未来展望》,载《情报杂志》2023 年第 1 期。

^② 参见梅傲、李准俊:《论〈数据出境安全评估办法〉与 DEPA 中数据跨境流动规则的衔接》,载《上海对外经贸大学学报》2023 年第 2 期。

^③ See Fengang Jiang, China's Legal Efforts to Facilitate Cross-border Data Transfers: A Comprehensive Reality Check, Asia Pacific Law Review, Vol. 32, No. 1, 2024, pp. 81-101.

^④ 2018 年通过《澄清合法使用海外数据法》(Clarify Lawful Overseas Use of Data Act, CLOUD 法案)形成数据控制者原则,不断降低“最低限度联系”门槛,赋予美国政府以国家安全为事由调取存储于其他国家主权域内数据权。

^⑤ 参见周念利、陈震琦:《RTAs 框架下美式数字贸易规则的数字贸易效应研究》,载《世界经济》2020 年第 10 期。

^⑥ 参见阙天舒、王子玥:《数字经济时代的全球数据安全治理与中国策略》,载《国际安全研究》2022 年第 1 期。

^⑦ 1953 年《欧洲人权公约》(European Convention on Human Rights)第 8 条规定:任何人对其私人和家庭生活、住所及通信均享有受尊重的权利。

^⑧ 根据联合国《2019 年数字经济报告》,中美占全球 70 个最大数字平台市值 90%,欧洲仅占 4%。See UNCTAD, Digital Economy Report 2019, United Nations Publications, 2019, p. xvi.

仅要求成员国不得以保护个人数据为由限制或禁止数据自由流动,还规定向区域外转移数据时需满足“充分性认定”的保护水平。^②然而,由于各成员国在将《指令》转化为国内法时存在差异,导致数据保护水平参差不齐,欧盟内部的数据跨境流动仍未能实现一致的同等级别保护。直到2018年《通用数据保护条例》(GDPR)正式生效,欧盟才真正形成了统一的数据保护规则。该规则继承了《指令》重要内核,并在数据跨境流动规制方面进一步完善,确立了严格的“事前保护”机制,要求第三国必须满足欧盟的“充分性认定”保护水平。对于未能通过“充分性认定”的国家或地区,跨国公司可通过具有约束力的公司规则(BCRs)或标准合同条款(SCCs)等替代工具实现数据跨境传输。^③上述一系列规则,不仅强化了欧盟内部的数据保护水平,也为全球数据跨境流动治理提供了重要参考。

吊诡的是,上述“公约”到“指令”再到“条例”的演进过程中,欧盟对数据跨境流动限制日趋严格,其中,虽然“充分性认定”规制范式在全球范围呈现出一定程度的扩张,^④但这种高标准机制在实践中因批准程序过于繁琐,反而形成了一种枷锁,阻碍了数据的自由流动。这种过度限制不仅压缩了其他国家相关企业在同等竞争水平下进入欧盟市场的机会,^⑤还因欧盟严格推行自身标准而对个人隐私保护实施苛刻限制,与数据自由流动的本质相悖。同时,欧盟严格按照自身标准推动个人隐私保护实施苛刻限制的效果与数据自由流动本性相悖。为减少数据保护法律风险,许多域外企业不得不停止欧洲业务,公民个人也望而却步,最终导致该范式下对个人隐私数据保护可能流于形式。此外,这种约束性范式也难以直接适用于中国作为数字大国的发展需求,其在实践中的局限性亦进一步凸显。

3. 新加坡全球兼容的“新式”非约束性范式

近年来,在美欧数据跨境规制博弈陷入僵局之际,新加坡作为全球贸易自由化程度最高的经济体之一,秉持开放态度,积极对接多边数据跨境流动规则。2018年新加坡加入APEC主导的CBPR,并积极开发与之对接的认证机制。同时,吸收借鉴OECD隐私规则,于2020年签署了RCEP,致力于打造亚太区域数据流动示范区。^⑥同年,新加坡再次联合大洋洲的新西兰、拉美的智利共同发起并签署了全球数字贸易治理领域首个专门性框架。^⑦这种以数字为中心、以模块为结构的开放性非约束协定,为全球加快数据自由转移、建立更加广泛的信任环境提出了新的路径选择。^⑧

在数据治理性质区分上,根据美国战略与国际研究中心(CSIS)发布的《亚太地区的数据治理》(Governing Data in the Asia-Pacific),数据治理可分为“贸易协定谈判”和“非约束性规则”两种类型。前者诸如CPTPP、RCEP等虽然具有较强的执行力,但谈判周期长,统一互信机制的建立难度较大。相比之下,新加坡主导的DEPA属于“非约束性规则”,具有高度的灵活性。DEPA采用模块化结构,缔约主体可根据不同场景自由选择适用的模块,从而显著提高协定的可操作性和适应性,为全球数据治理提供了更具弹性的解决方案。

在内容结构上,一方面,DEPA不仅涵盖常规贸易便利化发展条款,还拓展了一些未在CPTPP中讨论

^② See Clare Sullivan, EU GDPR or APEC CBPR? A Comparative Analysis of the Approach of the EU and APEC to Cross Border Data Transfers and Protection of Personal Data in the IoT era, Computer Law & Security Review, Vol. 35, No. 4, 2019, pp. 380—397.

^③ 参见赵若锦、李俊、张威:《新加坡数字经贸规则体系构建及对我国的启示》,载《国际贸易》2023年第12期。

^④ 欧盟在数据跨境流动国际规则制定中显示了超强影响力,不仅欧盟成员国将《指令》《条例》内容转化为本国数据保护法的具体规定,而且许多东欧、美洲、大洋洲国家及我国香港、澳门、台湾也都据此制定或修订了个人数据保护法律。参见周汉华:《探索激励相容的个人数据治理之道——中国个人信息保护法的立法方向》,载《法学研究》2018年第2期;许多奇:《个人数据跨境流动规制的国际格局与中国应对》,载《法学论坛》2018年第3期;洪延青:《推进“一带一路”数据跨境流动的中国方案——以美欧范式为背景的展开》,载《中国法律评论》2021年第2期;许可:《自由与安全:数据跨境流动的中国方案》,载《环球法律评论》2021年第1期;马光:《FTA数据跨境流动规制的三种例外选择适用》,《政法论坛》2021年第5期。

^⑤ 参见翁国民、宋丽:《数据跨境传输的法律规制》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2020年第1期。

^⑥ See Dusheng Zhai, RCEP Rules on Cross-border Data Flows: Asian Characteristics and Implications for Developing Countries, Asia Pacific Law Review, Vol. 33, No. 1, 2025, pp. 24—45.

^⑦ 参见宋瑞琛、冯纯纯:《中美数据跨境流动的国际法规制及中国的因应》,载《国际贸易》2022年第7期。

^⑧ 参见赵龙跃、高红伟:《中国与全球数字贸易治理:基于加入DEPA的机遇与挑战》,载《太平洋学报》2022年第2期。

的领域,例如对人工智能、金融科技创新等提出了包容性合作框架。另一方面,DEPA 作为非约束性规则,借鉴了 CPTPP 电子商务章节的相关条款,采用模块化设置,为各国提供了自由选择 16 个“模块化”软性包容性制度框架的灵活性,打破了传统区域贸易协定谈判中要求所有议题达成一致合意的硬性要求,最大限度地协调并兼顾各方的监管分歧,从而提升了各国的选择自主权和对该框架的接受度。

DEPA 签署后,新加坡加快推广“新式”数字贸易规则范式。《新加坡——澳大利亚数字经济协定》(SADEA)《欧盟——新加坡数字伙伴关系协定》(EUSDP)以及《英国——新加坡数字经济协定》(UKSDEA)的签署,标志着新加坡数字治理模式获得新进展。随着 DEPA 治理模式推广,新加坡全球兼容的“新式”范式为全球数字贸易时代数字经济治理提供了新的样本框架,为传统贸易协定探索出新的灵活性制度尝试。

二、DEPA 数据跨境流动治理新路径

DEPA 作为全球首个专门针对数字贸易形成的多边协定,已引起广泛关注。中国为深化改革开放和推动高水平对外开放,正式提交了加入 DEPA 的申请,不仅有助于顺利加入该协定,还能在合作中探索提升服务中小国家和发展中国家利益的数字贸易话语权。在此背景下,深入剖析 DEPA 模块 4 中有关数据跨境流动规制的三个议题尤为重要。

内容	个人信息保护			数据跨境自由流动			数据本地化存储	
	保护范围	内容设计	机制兼容互认	设置监管要求	数据范围	限制范围	设置监管要求	数据本地化正当性
DEPA	数字经济参与者	(1)构建保护体系 (2)形成法律框架 (3)形成非歧视规则	提升制度兼容性标准及保护信任标志	✓	以电子方式跨境传输数据,包括商业活动中个人信息	(1)目标所需限度内 (2)不得任意或不合理歧视或变相限制 (3)不得施加超出目标所需必要限制	✓	(1)不得任意或不合理歧视或变相限制 (2)不超出实现目标所需限度限制
CPTPP		(1)构建保护体系 (2)形成非歧视规则	缔约方可采取不同方式保护个人信息	✓			✓	
RCEP	电子商务用户	构建个人信息保护法律体系	各方在可能范围内合作	✓	不得阻止人为商业行为而通过电子方式跨境传输信息	(1)不得任意或不合理歧视或变相限制 (2)不得施加必要限制 (3)保护基本安全利益所需,其他缔约方不得异议	✓	(1)合法公共政策目标所需 (2)不得任意或不合理歧视或变相限制 (3)保护基本安全利益所需,其他缔约方不得异议

(一)第一个议题:个人信息保护

随着全球数据跨境流动的加速,个人信息中的行为模式数据更易被识别,且通过大数据分析可精准对其画像。少量数据的跨境流动可能通过画像技术损害个人或企业的权益,而大规模数据的跨境流动则可能对国家经济安全和社会稳定构成严重威胁。为此,新加坡在其主导的 DEPA 中,专门制定了“个人信息保护规则”,强调缔约方应加强对个人信息的保护,以构建相互信任的数字交易环境。相较于其他数字贸易协定,DEPA 在个人信息保护规制方面具有以下特点:

第一,扩大个人信息保护范围。一方面,与 CPTPP、RCEP 相较,DEPA 规则中个人信息主体保护范围不再局限第 4.2.2 条、第 4.2.4 条及第 4.2.5 条设计的“电子商务用户”单一主体限制,除此之外,协议第 4.2.1 条将个人信息主体保护范围延伸至“数字经济参与者”。^⑤ 另一方面,在个人信息保护内容中,RCEP 未对数据跨境流动是否包含个人信息形成清晰界定,而 DEPA 第 4.4.3 条及 CPTPP 第 14.11.2 条均明确将个人信息纳入数据跨境流动范畴,规定“每一缔约方应允许通过电子方式跨境传输信息,包括个人信息”,^⑥

^⑤ DEPA 第 4.2.1 规定:缔约方认识到保护数字经济参与者个人信息的经济和社会效益,以及此种保护在增强对数字经济和贸易发展的信心方面的重要性。

^⑥ DEPA 第 4.4.3 条规定:通过电子方式跨境传输信息缔约方确认它们在通过电子方式跨境传输信息方面的承诺水平,特别包括但不限于:每一缔约方应允许通过电子方式跨境传输信息,包括个人信息,如这一活动用于涵盖的人开展业务。CPTPP 第 14.11.2 条也规定:每一缔约方应允许通过电子方式跨境传输信息,包括个人信息,如这一活动用于涵盖的人开展业务。

置言之,任何可识别的个人信息均应准许通过电子方式跨境传输。此外,DEPA第4.2.8条、第4.2.9条及第4.2.10条进一步扩充了个人信息保护覆盖范围,将“数据保护信任标志”纳入其中,^⑦强化了个人信息保护的制度框架。总体而言,无论从个人信息保护的主体范围和保护内容上,DEPA规则层面均进行了延伸性扩充保护。

第二,细化规则具体内容设计。DEPA相较其他数字贸易规则,主要从以下方面对规则内容细化设计:其一,构建了较为完整的个人信息保护法律框架体系。DEPA第4.2.1条及第4.2.2条承继了CPTPP、RCEP制度设计,要求缔约方在数字贸易中充分考虑个人信息的重要性,并建立相应的法律框架,同时强调在制定框架时应参考相关国际机构的原则和指南,为各国达成一致数据保护水平奠定了基础。其二,明确了个人信息保护法律框架的基本原则。DEPA第4.2.3条体现了新加坡等中小国家在个人信息跨境流动问题上的折中立场,^⑧既未完全照搬美式规则中“自由传输为原则,限制为例外”的全球主义模版,也未完全趋附于欧盟严格人权隐私保护措施,而是借鉴了USMCA中除“选择”外的其他8项原则,^⑨形成了更具灵活性的保护机制。其三,确立了个人信息保护的非歧视规则。DEPA第4.2.4条与CPTPP类似,要求缔约方应在可能范围内合作,并不受管辖范围影响,对任何一方缔约方转移来的个人信息均应采取平等保护措施。^⑩虽然DEPA及CPTPP通过“非歧视”策略为各缔约国建立兼容性机制提供了可能,但目前为止,这两个协议均尚未提出明确操作要求。

第三,扩大个人信息保护机制的兼容互认,补充数据保护信任标志。一方面,DEPA借鉴USMCA的经验,倡议缔约各方建立兼容性沟通机制,允许各国根据自身国情制定差异化的个人信息保护规则,并引入数据保护信任标志等创新内容。^⑪与CPTPP相较,DEPA进一步扩大了兼容性范围,^⑫赋予各成员国充分选择空间,包括承认数据传输监管结果、认可各自法律框架下的可信任标志或保护水平等。同时,DEPA并未对强制性个人信息保护标准作出严格限制,而是允许各缔约国“采取不同法律方法”,从而为各国灵活选择适合自身制度的设计提供了可能。相比之下,RCEP仅要求缔约国在可能范围内合作,未对兼容性操作提出明确要求。另一方面,DEPA第4.2.8条还引入了“数据保护信任标志”,旨在验证企业是否符合个人数据保护标准。获得该标志的企业不仅能够便利个人信息的自由便捷转移,还能为各方主体提供更加安全可靠的制度保障,从而在促进数据跨境传输的同时有效保护个人信息。据此,DEPA倡议将该“标志”作为验证个人数据保护标准的重要监管工具,进一步提升了规则的实用性和可操作性。

(二)第二个议题:数据跨境自由流动

由美国主导的CPTPP等协定倾向于推动数据跨境自由流动,由中国推动的RCEP则更注重维护缔约国国内规制权。^⑬从条款内容来看,DEPA并非完全限制数据跨境流动,而是通过第4.3条的三款规则构建了递进层次的三重要求,旨在对限制措施进行合理规范,^⑭促使缔约方在非歧视原则下开展数据跨境流动。

第一重要求,增进互信互认,赋予缔约方基于安全利益自由选择裁量空间。DEPA第4.3条第1款通过

^⑦ DEPA第4.2.8条规定:缔约方应鼓励企业采用数据保护可信任标志,以帮助验证其符合个人数据保护标准和最佳做法。第4.2.9条规定:缔约方应就数据保护可信任标志的使用交流信息并分享经验。第4.2.10条规定:缔约方应努力相互承认其他缔约方的数据保护可信任标志,作为便利跨境信息传输的同时保护个人信息的有效机制。

^⑧ 参见靳思远:《全球数据治理的DEPA路径和中国的选择》,载《财经法学》2022年第6期。

^⑨ USMCA提出“限制收集、选择、数据质量、目的规范、使用限制、安全保障措施、透明度、个人的参与、问责制”等9项原则。

^⑩ DEPA第4.2.4条规定:每一缔约方应在保护电子商务用户不受其管辖范围内发生的违反个人信息保护行为的影响方面采取非歧视做法。

^⑪ 参见宋云博:《DEPA个人信息跨境流动的规制检视与中国法调适》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2024年第1期。

^⑫ CPTPP第14.8.5条兼容性机制主要包括:对监管结果的承认,无论是自主给予还是通过共同安排,或通过更广泛的国际框架。

^⑬ 参见王楚晴:《申请加入DEPA背景下中国数据治理的相容性审视及优化路径》,载《太平洋学报》2023年第3期。

^⑭ 参见霍俊先:《DEPA数据跨境流动:规制差异与中国因应》,载《国际经贸探索》2024年第3期。

承继 CPTPP 和 RCEP 等协议的制度设计,^⑤一定程度赋予缔约方基于安全利益的自由裁量空间,允许各国自主设置监管权限或通过与他国相互确认形成监管机制,从而构建互信互认的兼容性框架,促进了制度兼容性,为数据跨境流动的合理规范奠定了基础。

第二重要求,促使包括个人信息在内的数据自由流动。DEPA 第 4.3 条第 2 款明确允许以电子方式进行数据跨境流动,包括商业活动中的个人信息,并强调数据跨境自由流动应作为基本原则,禁止将监管要求转化为变相阻碍。^⑥值得注意的是,DEPA 与 CPTPP 规则设计中均对个人信息进行专门性强调,而 RCEP 并没有特殊强调要包括此类数据信息,^⑦这一差异反映了 DEPA 在数据流动规则上的更高标准和对个人信息保护的重视,同时也为缔约方在数据跨境流动中平衡自由化与监管需求提供了更具操作性的框架。

第三重要求,限缩公共政策例外范围。DEPA 第 4.3 条第 3 款与 CPTPP、RCEP 均采用了“原则加例外”的数据跨境流动模式,但在公共政策例外范围的限缩上,DEPA 与 CPTPP 更为严格。相较于 RCEP 对安全利益的宽松限制,DEPA 和 CPTPP 在公共政策目标例外中增加了“实现目标所需限度”的要求,^⑧强调基于合法公共政策目标所实施的措施应控制在目标所需限度内。^⑨这种制度内容设计旨在防止第一重规则中赋予缔约方的监管权限被滥用或扩大使用,同时间接提高了数据跨境自由流动的标准。相比之下,RCEP 第 12.4.15 条赋予缔约国更大的自由裁量权,不仅允许缔约方采取“对保护其基本安全利益可能所必需的任何措施”,还将范围扩大至所有“保护基本安全利益的措施”,并规定“其他缔约方不得提出异议”,从而为数据跨境流动设置了更多例外情形。而 DEPA 和 CPTPP 则通过更严格的例外条件,确保数据跨境自由流动的核心地位,并未赋予缔约方过多限制权限,体现了对数据自由流动的高度重视。

除此之外,在对 DEPA 数据跨境流动规则分析中发现,其“合法公共政策”例外性条款的表述过于宽泛,缺乏具体论述,可能导致在认定例外情形时缺乏法律确定性。具体而言,DEPA 未明确“合法公共政策”的判定标准是基于缔约国国内法还是共同签订的国际协定,这种模糊性可能在实际操作中引发争议,影响条款的认定、适用与解释。同时,DEPA 对“公共政策”一词的定义亦未形成统一论述。虽然 DEPA 与 CPTPP 均强调“合法公共政策目标”,但“公共政策”是否包含“国家安全利益”尚未达成共识。^⑩从文义解释来看,“公共政策”的外延远宽于“国家安全利益”,若不对其进行限制性解释,可能导致成员国利用理解偏差干预数据自由流动,甚至以泛国家安全为由滥用例外条款。因此,有必要对“公共政策”的范围进行明确界定,以避免条款被不当扩大适用。

(三)第三个议题:数据本地化存储

由于数据跨境自由流动可能削弱各国对数据的控制能力,数据本地化存储限制成为各国规制数据跨境流动的重要手段之一。^⑪对此,DEPA 在禁止数据存储本地化方面采取了更为积极的立场,鼓励缔约方作出更高水平的承诺。

第一,允许缔约方设置监管要求以降低在他国开展数字经济活动时可能面临的限制。DEPA、CPTPP 与 RCEP 均允许缔约方有权制定包括保障通信安全和通信机密在内的监管措施。这种安排倾向从保证通信安全及通信机密角度出发,既体现了对国家安全和公共利益的重视,也为缔约方在数据跨境流动与本地化

^⑤ DEPA 第 4.3 条第 1 款规定:缔约方认识到每一缔约方对通过电子方式传输信息可设有各自的监管要求。

^⑥ DEPA 第 4.3 条第 2 款规定:每一缔约方应允许通过电子方式跨境传输信息,包括个人信息,如这一活动用于涵盖的人开展业务。

^⑦ RCEP 第 12.4.15 条第 2 款规定:每一缔约方不得阻止涵盖的人为进行商业行为而通过电子方式跨境传输信息。

^⑧ 参见徐美玲、董静娴:《DEPA 数据跨境流动规则导向与因应》,载《科学管理研究》2023 年第 5 期。

^⑨ DEPA 第 4.3 条第 3 款规定:每一缔约方应允许通过电子方式跨境本条中任何内容不得阻止一缔约方为实现合法公共政策目标而采取或维持与第 2 款不一致的措施,只要该措施:(1)不以构成任意或不合理歧视或对贸易构成变相限制的方式实施;及(2)不对信息传输施加超出实现目标所需限度的限制。

^⑩ See Chris Noonan & Victoria Plekhanova, Taxation of Digital Services Under Trade Agreements, Journal of International Economic Law, Vol. 23, 2020, pp. 1015-1039.

^⑪ 参见朱雅妮:《〈数字经济伙伴关系协定〉的治理重心、推进策略及中国的加入谈判》,载《南昌大学学报(人文社会科学版)》2023 年第 5 期。

存储之间寻求平衡提供了灵活性,从而在促进数字贸易自由化的同时,兼顾对关键数据的安全保护需求。

第二,形成数据本地化措施的正当性。分析可见,DEPA 在数据本地化措施的正当性设计上,与其数据跨境流动限制规定保持一致,均允许基于合法公共政策目的设置例外情形。具体而言,DEPA 第 4.4 条第 2 款允许缔约方在特定条件下采取数据本地化措施,旨在通过限制东道国不得以他国在本国境内使用或安装计算设备为先决条件,为缔约国提供对数据本地化措施的抗辩机会,从而间接推动数据跨境自由流动。^② 同时,为防止滥用“基本安全利益”条款形成“长臂管辖”,DEPA 和 CPTPP 均删除了 RCEP 中基于“基本安全利益”目的设置的数据存储管制例外情形,从而对数据本地化措施的适用范围进行了限制。相比之下,RCEP 不仅允许在一般合法公共政策目标外增加保障国家基本安全利益的例外条款,还规定其他缔约方不得对此类措施提出异议。而 DEPA 第 4.4 条第 3 款对例外条款的适用提出了更为严格的要求,强调基于公共政策目标的措施必须在合理限度内使用,不得构成任意或不合理歧视,不得对贸易形成变相限制,且不得超过实现目标所需限度。^③ 这一设计体现了 DEPA 在平衡数据本地化与跨境自由流动之间的审慎态度,既保障了缔约方的规制权,又防止了例外条款的滥用,从而为数据跨境流动提供了更为稳定和可预见的规则框架。

仔细观之,DEPA 第 4.4 条虽然确立了“本地化为原则+合法公共政策为例外”的数据跨境本地化规制模式,但这一策略仍存在显著局限性。一方面,DEPA 要求东道国不得以其他缔约国在本国境内使用或安装计算设备为先决条件,这意味着数据跨境主体可将数据处理器等设施置于东道国领土之外。然而,这种安排引发了管辖权归属的难题:如何确定对跨境数据活动的管辖权?哪些机构有权调取相关证据?以及如何通过缔约国国内法或国际协定形成跨境证据搜集的执法依据?这些问题均成为该制度下亟待解决的法律适用困境。此外,随着人工智能技术的发展,如何在云存储服务中确保数据本地化安全存储也成为亟需应对的技术与法律挑战。另一方面,DEPA 第 4.4 条未对“合法公共政策目标”的具体例外情形作出明确规定,尤其是未明确由哪些主体对“合法”程度及“公共政策”覆盖范围进行解释。若主要由缔约方自行判定,可能导致“合法公共政策例外”被滥用,从而削弱规则的约束力。总体而言,如何进一步细化这些规则,明确例外情形的适用条件及解释主体,已成为当前保障数据跨境本地化存储的核心挑战,也是未来规则完善的重要方向。

三、中国数据跨境流动规则与 DEPA 的差异性

规制的目的并非单纯限制数据流动,而是为了在自由流动中维护安全与平等的平衡。^④ 中国作为数据资源超级大国,近年来在数据跨境流动规则的制定上取得了显著进展,不仅在广度上扩展了数据类型的覆盖范围、参与主体及数据要素流动的全过程,^⑤还在纵向上深化了对国家安全、个人隐私保护等关键领域的制度探索。为准确把握全球数字贸易规则的未来走向,并推动中国数字经济的高质量发展,有必要深入分析中国与 DEPA 等国际高水平数字贸易规则之间的差异,剖析毫厘、擘肌分理,及时对接并设计出既符合国际高标准又体现中国特色的数字贸易规则体系。

(一)个人信息保护制度构建

在个人信息保护议题上,随着对个人信息主权属性认识深化,我国对此形成了一系列相关立法规则,与 DEPA 具体内容相较,主要凸显以下特点:

第一,个人信息立法保护范围趋于扩大。数据控制主体是数据能否跨境的主要考察对象。对此,我国

^② 参见赵旸、彭德雷:《全球数字经贸规则的最新发展与比较——基于对〈数字经济伙伴关系协定〉的考察》,载《亚太经济》2020 年第 4 期。

^③ DEPA 第 4.4 条第 3 款规定:本条中任何内容不得阻止缔约方为实现合法公共政策目标而采取或维持与第 2 款不一致的措施,只要该措施:(1)不以构成任意或不合理歧视或对贸易构成变相限制的方式适用;及(2)不对计算设施的使用或位置施加超出实现目标所需限度的限制。

^④ 参见文铭、李星熠:《“自由—规制”框架下跨境数据流动治理及中国方案》,载《中国科技论坛》2024 年第 4 期。

^⑤ 参见郭德香:《我国数据出境安全治理的多重困境与路径革新》,载《法学评论》2024 年第 3 期。

《个人信息保护法》将个人信息保护主体范围扩大至一切“自然人”,^⑤相较于 DEPA 限定的“电子商务用户”或“数字经济参与者”,我国立法更具广泛性和包容性。此外,在个人信息保护内容方面,我国经历了从混合规制到区分监管的演变过程,但与 DEPA 涵盖“电子商务用户”或“数字经济参与者”不同,我国现行立法主要聚焦于个人用户,尚未将企业用户,特别是中小企业和跨国公司纳入保护范围。其中,2016 年通过的《网络安全法》作为我国首部系统性网络安全法律,主要针对“关键信息基础设施”产生的个人信息及“其他数据处理者”的情形进行规制,但未对个人信息与其他数据类型作明确区分。2021 年发布的《数据安全法》提出建立数据分类分级保护制度,同年通过的《个人信息保护法》进一步将个人信息划分为一般个人信息和敏感个人信息,2022 年实施的《数据出境安全评估办法》亦沿用了这种分类。整体而言,虽然我国立法已对数据类型进行了初步划分,但如何准确界定各类数据的边界,仍需在理论和实践中进一步研究。

第二,关于个人信息保护具体内容方面,我国当前立法与 DEPA 整体基本相同。主要表现在:一是,我国《个人信息保护法》中关于保护个人信息基本原则与 DEPA 保护水平较为一致。例如,《个人信息保护法》第 5 条强调处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则,^⑥第 6 条要求坚持目的限缩,第 7 条规定了透明性原则,第 8 条与 DEPA 均强调保证数据质量,第 9 条及第 7 章对应 DEPA 中的问责制,第 13 条、第 17 条要求信息处理者在处理信息中“获取当事人同意”和“向当事人告知”,体现了与 DEPA 相一致的个人参与原则。二是《个人信息保护法》第 43 条同 DEPA 均明确要求形成歧视性禁止,这一策略与 DEPA 的规定基本一致。

第三,在个人信息保护机制兼容性方面,我国《个人信息保护法》第 41 条提出与域外规则、标准互认的倡议,体现了与国际规则接轨的意图。具体操作中,该法第 39 条认为个人信息出境前,不仅需满足信息所有者知情权,使其了解境外接收方具体信息,还应征得其同意。第 40 条则对“关键信息基础设施运营者”和“达到规模数量的个人信息处理者”的个人信息设定了更为严苛的出境措施,^⑦尤其对于“确需”出境的情形,进一步要求开展安全评估。尽管 DEPA 允许在实现合法公共政策目标时设置例外,这与我国的安全评估机制在理念上具有兼容性,但 DEPA 仅笼统提及及相关措施,缺乏具体操作规定,可能导致在实际执行中难以与国际规则有效对接,更遑论开展国际执法合作。因此,我国在完善个人信息保护机制的同时,需进一步细化与国际规则的对接路径,以提升跨境数据流动的合规性和可操作性。

(二)数据跨境自由流动规制分析

从数据跨境自由流动规制的基本取向来看,我国国内法规制以数据主权主义为核心,构建了以数据跨境自由流动为主轴、本地化存储为例外的动态框架。这一框架与 DEPA 原则上禁止对数据跨境流动采取严格限制的理念存在一定差异。具体表现在:

第一,对于缔约方设置自身监管要求准许不同。DEPA 作为数字贸易领域的专门性治理范式,以极大的灵活性赋予缔约方基于安全利益自主制定监管要求的权利。相比之下,我国国内法在完善发展过程中,虽然强调与域外规则和标准的互认,但在是否允许缔约方设置监管要求的问题上,往往需通过对等互惠原则进行判断。这种差异反应了我国在数据主权与数据自由流动之间的谨慎平衡。为扩大数据跨境自由流动,未来在双边或多边数字经贸规则制定中,如何对标 DEPA 规则,赋予缔约各国在数据流动监管方面更大的自由裁量空间,将成为重要的法律议题。这不仅有助于提升我国数字贸易规则的国际化水平,也为构建更加灵活和兼容的全球数据治理框架提供了可能。

第二,在数据跨境自由流动整体规制倾向上呈现差异。从宏观角度看,我国主张的数据跨境流动是在安全评估或认证前提下的有限自由度,这与 DEPA 第 4.3 条所倡导的数据流动完全自由理念不同。具体而

^⑤ See Regina Becker & Davit Chokoshvili, Edward S. Dove, Legal Bases for Effective Secondary Use of Health and Genetic Data in the EU: Time for New Legislative Solutions to Better Harmonize Data for Cross-border Sharing?, International Data Privacy Law, 2024, Vol. 14, No. 3, pp. 223-242.

^⑥ 参见龙卫球:《〈个人信息保护法〉的基本法定位与保护功能——基于新法体系形成及其展开的分析》,载《现代法学》2021 年第 5 期。

^⑦ 参见张晓君、屈晓濛:《RCEP 数据跨境流动例外条款与中国因应》,载《政法论丛》2022 年第 3 期。

言,我国立法更注重数据跨境流动的安全性和合规性,而 DEPA 则更强调数据流动的自由化,这种差异反应了不同国家和地区在数据治理上的不同侧重点。自 2017 年《网络安全法》颁布至 2022 年《数据出境安全评估办法》实施,我国逐步构建了数据出境的审慎监管制度。^⑤ 2023 年《促进和规范跨境数据流动规定》进一步细化了数据出境安全评估、个人信息出境标准合同及个人信息保护认证等制度,缩小了安全评估范围。^⑥ 2024 年国家标准委员会通过整合《重要数据识别指南》发布的《数据安全技术数据分类分级规则》,为各地区和行业的重要数据识别规范奠定了基础。《个人信息保护法》颁布实施后,该法坚持“境内存储为原则、安全评估后出境为例外”的原则,^⑦对关键信息基础设施运营者和重要数据的跨境流动设置了较高门槛,而对其他数据处理者的数据出境仅设定了数量要求。相比之下,DEPA 在例外条款设计中排除了安全例外情形,这可能增加违法行为的发生概率,与我国“基于数据主权安全”前提下的数据跨境流动理念存在本质差异。这种差异不仅体现在政策层面,也影响了具体实施。在实际操作中,我国在数据分类和分级管理方面尚未形成统一标准,不同部门的执行存在较大差异,^⑧导致数据跨境流动的分类和分级问题复杂化。同时,现有的安全评估和管理机制在应对快速变化的数字经济环境时显得滞后和僵化,使得我国在对接 DEPA 等高标准国际经贸规则时面临较大挑战,亟需在保障数据安全的前提下,进一步完善规则设计。

(三)数据存储本地化规制

目前,我国国内法基于安全利益考量,偏重强调数据本地化存储,在数据跨境流动规则上与 DEPA 存在一定差异,特别是对涉及国家安全的数据保持高度审慎态度,但这并不意味着与 DEPA 规则完全无法相容。

第一,在允许成员国设置各自监管要求方面,我国国内相关立法已与 DEPA 形成一定衔接。如按照《个人信息保护法》第 41 条规定,对域外相关机构请求提供存储于境内的跨境个人信息时,应按照平等互惠原则予以处理。这表明我国在个人信息跨境处理方面并未完全依赖本地化存储的立法规制,而是优先适用国际条约规则和双边互惠原则。然而,如何具体衔接这些规则,目前尚未形成明确的可操作规定。与此同时,DEPA 允许缔约国设置各自的监管要求,并将数据处理器设置于境外,这一规定在促进数据跨境流动便利性的同时,也可能引发一系列潜在问题。首先,由于各缔约国可根据自身法律法规制定不同的监管要求,若发生争端,可能导致多个国家对同一数据行使管辖权,而各国法律规定和执法力度的差异使数据处理难以同时满足各方要求。其次,DEPA 允许数据处理器设置于境外,导致数据的实际控制权分散在不同国家和地区,这不仅增加了数据泄露的风险,还可能因部分国家和地区的网络安全防护水平较低而成为黑客攻击的目标。

第二,对于数据本地化措施的正当性问题,DEPA 和 CPTPP 均将“基本安全利益”排除在例外条款之外,这种设计易造成数据安全合理监管权滥用。如上所述,DEPA、CPTTP 均删除了 RCEP 中基于“基本安全利益”目的的数据本地化存储例外条款,这种排除“基本安全利益”的设置,可能与数据本地化存储的实际需求产生冲突,尤其是在数据跨境流动过程中,难以及时形成数据本地化存储的正当性法律依据。对此,我国立法虽同样未将“基本安全利益”作为例外情形,但在实际操作中主要以国家安全为由实施数据本地化要求。例如,《数据安全法》第 24 条规定,涉及国家安全、经济发展和社会公共利益的重要数据应在中国境内存储,确需向境外提供时须经过严格的安全评估。^⑨ 这种规定的主要目的是防止重要数据的外流,从而保护国家的核心利益。同时,《个人信息保护法》第 36 条要求国家机关处理的个人信息原则上在境内存储,确需向境外提供时须通过安全评估;该法第 40 条进一步规定,关键信息基础设施运营者及处理个人信息达到规定

^⑤ 《数据出境安全评估办法》《个人信息跨境处理活动安全认证规范》《个人信息出境标准合同规定(征求意见稿)》的颁布,建立了“安全评估审查下的高风险数据有限流动、标准合同和认证机制下的低风险数据自由流动”的数据出境评估体系,体现出监管部门对数据安全评估呈现十分审慎的态度。

^⑥ 参见金歆:《国家网信办公布〈促进和规范数据跨境流动规定〉》,载《人民日报》2024 年 03 月 23 日第 5 版。

^⑦ 参见彭鐔:《论国家机关处理的个人信息跨境流动制度——以〈个人信息保护法〉第 36 条为切入点》,载《华东政法大学学报》2022 年第 1 期。

^⑧ 参见黄先海、周禄松:《全球数字贸易规则比较、挑战与中国应对策略——基于 CPTPP、DEPA 与 RCEP 比较视角》,载《社会科学战线》2024 年第 1 期。

^⑨ 参见齐鹏:《“一带一路”数字经济数据跨境风险的系统性应对逻辑》,载《西安交通大学学报(社会科学版)》2021 年第 5 期。

数量的处理者,其个人信息也须在境内存储,出境时需经过安全评估。^④然而,现行立法对“重要数据”和“个人信息”的具体范围、数量规模以及安全评估的具体操作程序尚未明确,导致在实际执行中存在模糊性。总体来看,我国立法在数据本地化存储的例外情形必要性问题上与 DEPA 规则存在一定冲突,DEPA 强调数据跨境流动的自由化和便利化,而我国更注重数据安全和隐私保护。因此,如何在保障数据安全的前提下,平衡数据自由流动与安全保护的关系,也成为需要进一步研讨的重要议题。

四、DEPA 视域下我国数据跨境制度的对接应对方案

当前,数字经济已成为重塑全球经济结构的核心力量。虽然我国已出台了一系列相关法律法规,但在个人信息保护、数据跨境流动、数据存储本地化规则设计及灵活适用方面,与 DEPA 的要求仍存在一定差距。为对接 DEPA 高水平保护规则,最大化释放数据要素价值,有必要坚持“合作包容性”价值理念,在中国式涉外法治现代化语境下,从以下方面结合我国国内数字法规发展方向和国家利益,对上述问题加以回应。

(一)衔接个人信息安全保护规则,强化机制兼容互认

为更好调适融通我国国内法与 DEPA 个人信息跨境流动规则,有必要从以下方面形成破题之道:

第一,扩大个人信息保护的边界。明确保护对象的边界是精准对接国际规则并服务相关群体的前提。一方面,在扩充个人信息主体保护范围时,应秉持审慎原则制定保护目录,不仅涵盖一般个人用户,还应将各类企业用户,特别是将中小企业和跨国公司纳入保护范围。同时,需重点关注特定群体的信息保护,如弱势群体、特定职业群体的隐私信息。另一方面,在延伸和扩充个人信息保护内容时,应借鉴 DEPA 规则将保护范围从静态数据活动扩展至数据跨境流动的全生命周期,包括数据的收集、使用、共享、传输和存储等动态环节。

第二,构建个人信息保护法律体系。一要建立全面的个人信息保护法律框架及操作指南。对标 DEPA 规则,明确个人信息保护的立法目标和原则,详细规定数据控制者与处理者的权利和义务,针对不同行业制定具体的保护标准,并编制涵盖数据全生命周期的操作指南。二要完善个人信息法律基本原则。一是坚持透明性原则,要求数据控制者在收集信息前明确告知信息主体数据的使用用途、处理方式及其权利;二是完善目的限制原则,规定个人信息只能用于收集时明确的合法目的,不得随意变更用途;三是落实最小化原则,定期清理不再需要的数据存储量;四是强化准确性原则,允许信息主体定期更新其个人信息,确保数据的准确性;五是明确存储限制原则,规定个人信息的存储期限应以实现目的所需的最短时间为限;六是健全责任制原则,明确数据控制者和处理者的责任,对违反个人信息保护规定的行为追究法律责任。三要完善数据跨境传输中的个人信息保护非歧视具体操作规则。DEPA 和 CPTPP 提出了“非歧视”兼容性倡议,但未明确具体操作要求。我国可借鉴国际公认的个人信息保护标准,确保国内法规与国际规则一致,并积极参与制定全球统一的个人信息保护标准。同时,应平等对待国内和跨境数据传输行为,避免任何形式的歧视性措施。

第三,强化数据跨境传输中个人信息保护机制的兼容互认。为扩大保护机制的兼容互认,可采取以下具体策略:一要建立数据保护标准互认监管机制。一方面,推动建立统一的数据保护安全认证体系,鼓励企业通过认证,确保其保护措施符合国际标准,并在不同国家和地区实现互通互认;另一方面,设立数据跨境保护联合监管机构,负责协调和监督跨国数据传输中的个人信息保护。二要借鉴 DEPA 数据发展方案,以数据服务器本地化为要求,加快构建中国离岸数据中心,出台数字身份认证标识,推进数据沙箱实验和应用,减少区域内贸易流动障碍。三要尝试引入 DEPA 数据跨境传输中的“数据保护信任标志”机制。一方面,邀请行业专家和企业代表,制定符合国情的信任标志标准,并根据数据保护措施的完善程度和合规性,设立基本级、增强级和高级等多级信任标志体系;另一方面,健全“数据保护信任标志”的认证机制,包括申请程序、评估审核、认证机构、宣传推广、年度审核和投诉处理等流程,提升信任标志的公信力。

(二)对接数据跨境流动规则,平衡数据流动与安全发展

近年来,我国数据跨境流动立法工作不断加强,但与 DEPA 等相关国际协定协调问题依然存在。为此,需提出兼顾数据安全的规则对应路径:

^④ 参见徐莉:《跨境数据流动规制之“合法公共政策目标例外”与中国实践》,载《求索》2023年第4期。

第一,秉持“构建数字空间命运共同体”的价值理念,强化国际合作,筑牢数据跨境流动的安全防线。首先,在确保数据安全可控的前提下,应积极参与国际数据规则议题谈判,推动形成公平、包容的全球数据治理框架。根据域外相关国家的数据保护对等原则,建立动态数据跨境流动“白名单”机制,通过识别和认可数据保护水平与我国相当或更高的国家或地区,允许其数据在更少限制下流入我国,从而促进数据跨境流动的便利化。其次,应加强与重要贸易伙伴国的数据流动认证合作,确保这些国家的数据保护措施能够有效保障我国公民和企业的数据安全,同时为我国企业参与国际竞争提供制度保障。此外,重点推进“一带一路”倡议合作框架下的数据流动协议与标准制定,^⑤构建和完善符合中国特色的数字交互操作性规则,探索成员之间兼容且可交互操作的数据治理机制,鼓励各成员对相关机制形成相互承认,为深化我国与“一带一路”沿线国家的经济合作,加强沿线国家数据流动和保护提供明确的指导和规范。

第二,准确把握数据流动和安全发展的平衡点。尽管我国法律要求某些关键数据必须存储在国内,但这并不意味着完全禁止数据流向境外。^⑥事实上,我国数据本地化要求与 DEPA 数据规则并非无法兼容。数据流动是数据增值的重要路径,但若缺乏有效控制,也可能带来潜在风险。为此,一要强化在数据自由流动的前提下充分保障数据安全。^⑦首先,发布详尽的数据出境安全评估分级目录,特别是对涉及国家安全的重要数据进行重点分级;其次,制定针对关键信息基础设施和个人信息保护,形成数据出境安全评估的管理办法;最后,对于非重要数据,则允许在保障安全的基础上自由跨境传输。二要在加入 DEPA 的谈判进程中,为我国数据本地化规则提供合法依据,通过双边条约或国际组织认证机制等形式,^⑧协调 DEPA 与 RCEP 在数据流动规则上的差异,形成与 DEPA 相一致的例外条款,避免规制差异对我国加入 DEPA 产生负面影响。三要充分发挥自贸区(港)的制度优势,制定“港”“区”化发展路线图。对此,可先行设立数据跨境流动“数据贸易港”,打通对接 DEPA 国际高标准数字经济规则的通道,在符合 DEPA 公共政策目标的前提下“先行先试”,探索对数据跨境流动的有限限制。当“数据贸易港”中 DEPA 规则对接的风险控制在可控范围内后,将成功经验复制推广至全国,最终打造与 DEPA 规则相接、流动风险可控的“数据贸易区”。

(三)接合数据本地化存储规则,规范例外适用情形

目前,我国《网络安全法》和《个人信息保护法》以国家安全及个人信息安全为出发点,要求部分数据在境内储存。这种限制性措施与 DEPA 所鼓励的数据跨境自由流动并禁止数据本地存储要求存在一定差距。^⑨为对接 DEPA 高标准数字经济协定,避免国内外规则脱钩,可以进行以下探索:

第一,形成与 DEPA 各国立法互相尊重的透明规则。在与 DEPA 具体衔接中,应充分尊重不同国家的价值诉求,构建“网络空间命运共同体”。一要提高透明度并建立通知机制。成员国在设置或调整数据本地化要求时,应遵循透明度原则,及时通知其他成员国并公开相关信息,包括本地化要求的理由、范围和实施细则,确保其他成员国和企业能够清楚了解并遵守这些规定。二要加强成员国之间在数据保护和本地化要求方面的互认探讨与合作。一方面,通过协商推动成员国法律和监管框架的统一与协调,使各国数据保护和本地化法律在目标和执行上趋于一致;另一方面,共同商定哪些情况适用 DEPA 规则,哪些情况适用成员国国内法律,并通过补充协议或附加条款确保数据本地化和流动中法律适用的界限清晰。三要建立透明的数据跨境流动政策。成员国在实施数据本地化要求或其他数据监管措施时,应公开说明理由、范围和具体要求,确保其他成员国和相关利益方了解规定。同时,建立定期评估机制,定期回顾和更新相关政策和措施,确保规则的适应性。

第二,加强与 DEPA“本地化为原则+合法公共政策为例外”的数据跨境本地化模式相衔接。一要设置灵活的例外条款,以增强各国在数据保护和管理上的互信。为提升数据自由流动的效率和便捷性,可设立

^⑤ 参见齐鹏:《“一带一路”数字经济数据跨境传输共享治理场景建构》,载《北京工业大学学报(社会科学版)》2022年第2期。

^⑥ 参见马其家、李晓楠:《论我国数据跨境流动监管规则的构建》,载《法治研究》2021年第1期。

^⑦ 参见许可:《自由与安全:数据跨境流动的中国方案》,载《环球法律评论》2021年第1期。

^⑧ 参见赵海乐:《论我国数据本地化措施与 FTA 缔约的协调》,载《国际经济法学刊》2022年第2期。

^⑨ 参见文洋、王霞:《DEPA 规则比较及中国加入路径分析》,载《国际商务研究》2022年第6期。

“视为当事人同意”机制,即当数据跨境流动符合特定前提条件或标准时,可视为数据所有者已同意该过程,从而简化审批程序,促进数据在不同国家间的顺畅流动。同时,设立“视为达到与我国相当的数据保护水平”情形,若评估结果显示某国或地区的数据保护水平与我国相当,则允许数据自由跨境流动。二要排除“基本安全利益”的模糊性规定。为避免例外条款的滥用,需将“基本安全利益”限制在可控范围内。一方面,在数据分类分级管理中,明确“基本安全利益”的范围,将其限定为与国家核心职能紧密相关的领域,如保护领土免受外来威胁及维护境内公共秩序;另一方面,在实施数据本地化要求时,提高透明度,详细说明实施数据本地化的合法公共政策理由、法律依据及适用范围和时间限制。三要明确“合法公共政策例外”的具体情形。为避免概念模糊,应明确规定各成员国共同判定数据本地化存储的“合法”程度,并详细列举允许本地化的“公共政策”情形。可参考国际惯例和其他国际协议,将“合法公共政策”限制在以下领域:保护国家安全,包括防止恐怖主义、网络攻击等威胁;维护公共秩序和安全;保护公共健康,如应对公共卫生紧急情况 and 疾病防控;以及保障消费者权益,防止欺诈和不公平商业行为等。

五、结语

中国加入 DEPA 不仅标志着继 RCEP 之后对更高水平数字治理理念和规则的接纳,也为应对欧美国家的压力与挑战提供了重要契机。然而,国内现行的数据跨境流动规制与 DEPA 等高水平数字经济规则间仍存一定张力。因此,在推进与 DEPA 规则对接的过程中,中国需结合国内数字经济发展的实际情况,审慎评估 DEPA 协定的具体内容,避免盲目全盘接受,应立足自身数字贸易发展的实际需求,提出符合国情的本土化数据治理规则方案,既推动国内规制体系的完善,又通过“中式”模板提升国际影响力,为构建更加公平合理的全球数字贸易治理新格局贡献中国智慧。

Abstract: The Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) is the world's first digital trade agreement. China's accession to DEPA is a significant move to establish global digital trade partnerships under the new development paradigm, demonstrating China's commitment to open, innovative, and inclusive development. It also represents a crucial step in promoting and leading the global governance of the digital economy. To bridge the gap with DEPA's "new-style" data governance rules, it is necessary to focus on three issues in DEPA Module 4 regarding cross-border data flow regulations: "personal information protection, cross-border data flow, and data localization storage." This involves analyzing the current global multi-polar governance landscape of cross-border data and the operational status of DEPA, comparing the differences between China's and DEPA's cross-border data flow rules, and exploring a "Chinese-style" solution for cross-border data flow that aligns with DEPA. The proposed solution includes: first, aligning with personal information security protection rules to strengthen mechanism compatibility and mutual recognition, which involves expanding the boundaries of personal information protection, constructing a legal system for personal information protection, and enhancing the compatibility and mutual recognition of personal information protection mechanisms in cross-border data transfers. Second, aligning with cross-border data flow rules to balance data flow and security development, which entails adhering to the value concept of "building a community with a shared future in cyberspace", strengthening international cooperation to establish a security defense line for cross-border data flow, and accurately grasping the balance between data flow and security development. Third, integrating data localization storage rules to standardize exceptional application scenarios, which involves forming transparent rules that respect the legislation of DEPA member countries and enhancing alignment with DEPA's data localization model, which is based on "localization as the principle + legitimate public policy as the exception."

Key Words: Cross-Border Data Flow; DEPA; Personal Information Protection; Data Localization

(责任编辑:李安安)